

1501317-60.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... envolvido na prática do crime de tráfico de drogas. Primeiramente, veja-se que não há indícios suficientes de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas, sendo certo que sua versão não foi infirmada pelo restante da prova coligida. Vale ressaltar que o Acusado não foi visualizado em atividade típica de traficância, não trazia dinheiro consigo e não fazia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501317-60.2021.8.26.0571 - Controle 2021/001443

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE PEREIRA COSTA

Data da Audiência:

18/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Henrique Pereira Costa. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Maycon Douglas Cassemiro e Gustavo Henrique Gomes arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. JUIZ: O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c. c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, trazia consigo, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 1,98g (um grama e noventa e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os autos de exibição e apreensão, constatação e laudo definitivo da droga estão encartado a fls. 14, 17/18 e 170/173, respectivamente. A denúncia foi oferecida, o réu foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida e o réu foi citado. Na audiência de instrução e julgamento, o acusado foi interrogado e foram ouvidas testemunhas, sendo encerrada a instrução. É a síntese do necessário. Douto Julgador, o pedido deve ser julgado PROCEDENTE para CONDENAR o réu nos exatos termos propostos na denúncia.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhando de rotina no bairro acima mencionado, instante em que visualizaram o acusado em via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, HENRIQUE saiu andando apressadamente em direção oposta, dispensando uma sacola branca no interior de uma lixeira. Em razão de tais fatos, os policiais resolveram abordá-lo. Na diligência, recuperada a sacola por ele dispensada, os militares encontraram todas as porções acima mencionadas, prontas para a imediata alienação. Ante a inequívoca situação de flagrante, os policiais deram voz de prisão a HENRIQUE, conduzindo-o a solo policial para as demais providências. Como se vê, a dinâmica dos fatos – convergência de todos os detalhes da diligência – demonstra que o acusado possuía todas as porções para fins de tráfico. O crime foi cometido em plena pandemia da “Covid-19”. A materialidade da infração penal está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória e do laudo de exame químico-toxicológico. Quanto à autoria, também não restou a menor dúvida. Sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática da infração penal, alegando que caminhava pelo local quando foi abordado pelos policiais e que não dispensou nenhuma sacola na lixeira e que não trazia droga consigo. Em que pese o esforço empreendido pelo acusado, na tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, verifica-se que a versão apresentada por ele restou ilhada nos autos, cercada pelos demais elementos de prova amealhados no curso da instrução criminal, motivo pelo qual merece desprezo. As provas carreadas aos autos são suficientes para incriminar o réu. As testemunhas ouvidas confirmaram o teor da denúncia. Relataram que se encontravam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando o réu, ao avistar a viatura, saiu andando apressadamente, em direção oposta, bem como dispensou uma sacola plástica de cor branca dentro de uma lixeira que estava no caminho. Assim, resolveram abordar o réu e feita a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, ao questionarem Henrique a respeito do que ele tinha jogado na lixeira, ele negou o fato. Relataram que foram até a lixeira e localizaram a sacola de cor branca, que Henrique tinha dispensado anteriormente e no seu interior foram encontrados 26 porções de cocaína. Por fim, disseram que pesquisaram os antecedentes do réu e verificou-se que ele havia sido preso fazia um mês pelo mesmo crime no mesmo local. Acrescento que, relativamente aos depoimentos de policiais, a jurisprudência sabiamente sedimentou a questão, reconhecendo o valor do depoimento daqueles, quando os autos não apresentem elementos que indiquem que tal prova não deva ser considerada. Ora, seria uma manifesta contradição o Estado credenciar agentes para atuar na área da segurança pública e investigar a prática de crimes e não acreditar em seus depoimentos em Juízo, cabendo lembrar que os policiais também são devidamente compromissados. Não se pode olvidar a presunção de lisura dos atos praticados por policiais, que, até prova em contrário (que nestes autos não foi produzida pelo réu), deve prevalecer. Aliás, nestes termos pronunciam-se os nossos Pretórios: “O depoimento de policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do agente, se reveste de especial valoração probatória pela premissa de que o servidor público, investido de autoridade, tem o dever funcional de contribuir para a apuração da verdade real e aplicação da lei penal” (STF - HC 119067 PR. Relator Min. LUIZ FUX. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: DJe-171, 02/09/2013). “Neste compasso, ou seja, em relação à palavra dos policiais, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.” (STJ - AREsp 302955 SP 2013/0065939-3. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJ 15/10/2014). Assim, é inolvidável que as circunstâncias que rodearam os fatos nos levam à segura conclusão de que se desenvolveram exatamente da forma descrita na denúncia. Além da prova oral, outra circunstância que permite deduzir que as substâncias se destinavam à mercancia é justamente a quantidade e forma de acondicionamento dos psicotrópicos apreendidos, o que não deixa dúvida de que o réu

se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes, até porque um mês antes desta prisão o réu havia sido preso no mesmo local pela prática do mesmo crime que o apurado nestes autos. Nestes termos, demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal descrita na denúncia, a condenação do réu nos termos acima propostos, é medida que se impõe. No tocante à dosimetria, a pena deverá ser fixada no mínimo legal. A seguir, presente a agravante descrita na denúncia a pena deverá ser majorada. Ante a ausência de outros fatores que poderiam interferir na dosimetria, a pena se torna definitiva. Por se tratar de crime de tráfico de entorpecentes, considerando a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, o regime para o início do cumprimento da pena deverá ser o fechado. Mesmo que eventualmente a quantidade da pena imposta permitisse que fosse estabelecido regime inicial mais benéfico e a substituição da reprimenda, tais efeitos sempre dependerão, em última análise, do exame da culpabilidade do agente, de seus antecedentes, de sua conduta social, de sua personalidade, bem como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Dessa forma, diante da análise do caso concreto, consoante os termos dos arts. 59 e 33 do CP, levando-se em consideração a conduta e as gravíssimas consequências causadas à sociedade pelo crime de tráfico de entorpecentes, impõe-se a adoção do regime mais gravoso. Assim, a modalidade menos severa para o cumprimento da pena se mostra insuficiente e inadequada à repressão do delito. Diante de todo o exposto, aguardo seja a ação penal julgada PROCEDENTE para que o réu seja CONDENADO nos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: Segundo consta na denúncia, o dia 06 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo drogas que supostamente seriam destinadas ao tráfico. Em razão disso foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou sua defesa preliminar. A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 18 de janeiro de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e o réu foi interrogado. Os policiais narraram que estavam em patrulhamento na Vila Arruda, local já conhecido pelo intenso tráfico de droga. Ao se aproximarem do Acusado o réu teria se afastado e colocado algo numa lixeira. Realizaram a abordagem e nada ilícito foi encontrado. Olharam a lixeira e encontraram uma sacola com vinte e seis pinos de cocaína. Às perguntas da defesa, narrou que não havia mais pessoas nas imediações próximas ao Acusado e que já haviam abordado ele na região anteriormente. Ao ser interrogado, o Acusado narrou que estava andando na rua. Passou ao lado da lixeira, mas não dispensou nenhuma droga. Afirmou que é usuário de cocaína. A versão apresentada pelas testemunhas acusatórias não é suficiente para demonstrar além de qualquer dúvida razoável que o Acusado estivesse envolvido na prática do crime de tráfico de drogas. Primeiramente, veja-se que não há indícios

suficientes de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas, sendo certo que sua versão não foi infirmada pelo restante da prova coligida. Vale ressaltar que o Acusado não foi visualizado em atividade típica de traficância, não trazia dinheiro consigo e não fazia contato com nenhuma outra pessoa. Por outro lado, deve ser ressaltado que os policiais afirmaram que o Acusado teria dispensado algo, contudo, os próprios policiais afirmaram que não conseguiram visualizar o que o Acusado poderia ter descartado no lixo. Ainda, não parece crível que a lixeira de rua não tivesse nenhum item, apenas a sacola contendo os entorpecentes. Assim, pelo conjunto probatório não há como saber, sem qualquer margem de dúvidas, se a sacola estava anteriormente em posse do Acusado ou se já estava sendo ocultada na lixeira por outras pessoas, mormente porque os próprios policiais afirmaram que o local de patrulhamento é de intensa atividade de tráfico. Ademais, é necessário salientar que o Acusado é primário. Outrossim, declarou-se usuário de maconha, crack e cocaína desde a sua prisão.. Assim, requer a improcedência da ação penal, nos termos do art. 386, VII do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28, caput, da lei de Drogas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da eventualidade, passa-se à análise da dosimetria da pena a ser imposta ao acusado. Na primeira fase, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de requisitos capazes de

exasperá-la, nos termos do art. 59 do Código Penal. Muito embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça como critério para a dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é impossível a aplicação de tal norma, na medida em que é difícil avaliar qual quantidade e quais variedades de drogas seriam suficientes para justificar a aplicação da causa de diminuição abaixo do máximo estabelecido em lei. Assim, a inexistência de tal parâmetro faz com que a aplicação de pena seja feita de maneira completamente arbitrária. Na segunda fase, não incidem agravantes, haja vista a primariedade do acusado. A agravante de calamidade pública descrita na denúncia deve ser afastada, uma vez que é indispensável a prova do nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico. Ainda, incide a atenuante da idade do réu, que tinha apenas 19 anos na data dos fatos. Na terceira fase, de rigor a aplicação do redutor do tráfico, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Vejamos: Veja-se que não ficou comprovado nos autos que se dedique a práticas criminosas ou que integre organização criminosa, preenchendo então, todos os requisitos do redutor. Aqui, deve ser observada a regra de tratamento que emana da presunção do estado de inocência, não podendo se admitir que processos ainda em tramitação sejam utilizados para presumir-se a dedicação do Réu em atividades ilícitas. Com efeito, o fato de o Acusado responder a outro processo não o impede de receber o redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, com base no princípio da presunção do estado de inocência que somente é afastado com condenação judicial definitiva, nos moldes da mais recente interpretação do E. Supremo Tribunal (HC 187.180/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Data de julgamento: 19/06/2020). Com efeito, em consulta aos autos n. 1501052-58.2021.8.26.0571, verifica-se que se trata de feito ainda em tramitação, para apreciação do recurso de apelação defensivo. É justamente por essas razões, amparadas em precedentes da E. Suprema Corte, que se requer a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Isso porque, a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado. De tal forma, ante as peculiaridades do caso em tela, claro está que não há razão para a determinação de regime fechado, ainda que não se aplique o redutor em seu grau máximo. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o artigo 44 foi considerado inconstitucional pelo E. STF (HC n. 97.256/RS), o que motivou a expedição da Resolução n. 05, de 2012, do Senado Federal, suspendendo, nos termos do art. 52, X, da CF a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar o acusado de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos. HENRIQUE PEREIRA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, inc. II, alínea “J”, do Código Penal, porque, no dia 06 de outubro de 2021, em período de anormalidade – Pandemia, por volta das 18 h, na Rua Evilásio Massaine Pires, próximo ao número

1071, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e seis porções de "cocaína", com peso de 1,98 gramas. O Réu foi notificado, fls. 94, e apresentou defesa preliminar, fls. 100/101. A denúncia foi recebida, fls. 104/105, e o Réu, citado, fls. 119. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 11/13, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 14, bem como no Laudo de Constatação, fls. 17/18 e de Exame químico-toxicológico n. 330.827/2021, fls. 70/739, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Maycon Douglas Cassemiro e Gustavo Henrique Gomes, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, que, ao ver a viatura, saiu caminhando no sentido oposto e jogou algo em uma lixeira; abordado, com ele nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro da lixeira, os policiais localizaram uma sacola com 26 pinos de "cocaína"; indagado, o Réu negou que tivesse jogado algo. O Acusado é conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes e já foi preso anteriormente por essa razão. Não havia outra pessoa no local. Henrique Pereira Costa, Réu, ao ser interrogado, disse que realmente caminhava pela via pública, passou ao lado da lixeira, mas nada jogou. É usuário, responde a outro processo por tráfico de entorpecentes e trabalhava. Confrontando-se a prova coligida e de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu era o proprietário dos entorpecentes, destinados à venda, uma vez que ele, ao ver os policiais, dispensou dentro da lixeira uma sacola dentro da qual havia 26 pinos de "cocaína", drogas que, pela quantidade de porções, eram destinadas ao comércio ilícito. O Réu negou a acusação, mas sua versão restou isolada e inverossímil. Não havia outra razão para o Réu estar naquele local, com aquela quantidade de drogas, exceto a prática do tráfico de entorpecentes. A circunstância de não haver outra pessoa naquele local e naquele momento não elide a prova do comércio ilícito, uma vez que o Réu lá estava à disposição de interessados, cuja presença naquele local não era a primeira vez, pois se trata de Acusado já preso anteriormente por tráfico de entorpecentes e contra quem já havia denúncias pretéritas. As testemunhas não têm motivos para incriminar um inocente. Para que seja valorada a veracidade ou idoneidade do relato policial, não há necessidade de confirmação do apurado por pessoa estranha aos quadros da Polícia. Absurdo seria admitir-se situação contrária. Não se conhece razão plausível para que os policiais arquitetassem diabólico plano visando incriminar este Réu, apontando-a como autor dessa espécie de crime. Tudo indica que os policiais agiram com lisura e, por certo, não se poderia desacreditar o relato de cada qual, uma vez que apenas tais agentes é que presenciaram e participaram da diligência de localização da droga, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são investidos de poder para tal função. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Não seria lógico o Estado contratar agentes para a segurança pública, investindo-os de parcela do poder estatal e, ao serem chamados a Juízo, não lhes emprestar credibilidade. Os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Destarte, o Réu trazia consigo substâncias entorpecentes, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação

múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do Agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Conforme se verifica nas certidões de fls. 42 e de fls. 43/44, o Réu possui processo em andamento e medidas sócio - educativas aplicadas pela Vara da Infância, todavia não podem ser consideradas em seu desfavor; destarte, as circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", não pode ser acolhida. Com efeito, a incidência da agravante da calamidade pública exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que implique maior gravidade, e não há nexo de causalidade entre a ofensa ao bem jurídico e a pandemia do novo coronavírus. O Réu é menor de 21 anos, logo faz jus a atenuante. Todavia, na segunda etapa, a atenuante não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar HENRIQUE PEREIRA COSTA, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário

- mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu preso ao processo, porém, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 18 de janeiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA